

1502225-31.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: NAIRA BLANCO MACHADO

Comarca: Arujá

Foro: Foro de Arujá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/09/2022

... - pela inaplicabilidade da lei de crime hediondos a hipóteses de tráfico privilegiado, como o presente caso:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA .1. O tráfico de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Arujá

Foro de Arujá

1ª Vara

Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja - SP - cep 07400-000

1502225-31.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502225-31.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAURICIO BARBOSA DE SOUSA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NAIRA BLANCO MACHADO

Vistos.

MAURICIO BARBOSA DE SOUZA, qualificado no autos, foi denunciado pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque em 27 de agosto de 2021, por volta das 18:30 horas, na Rua Quarenta e Oito, 218, Parque Rodrigo Barreto, nesta cidade, trazia consigo para fins de venda, 23 papelotes de cocaína(10,32 gramas - massa líquida), 14 trouxinhas de maconha (36,09 gramas - massa líquida) e 12 eppendorfs de crack (1,08 gramas - massa líquida), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narra a acusação que o acusado estava na via pública vendendo drogas, ficando parado em frente de uma casa e de tempos em tempos recebia pessoa que falava com ele. O acusado então se retirava e deslocava-se até a viela ao lado, de onde voltava para entregar algo a esta pessoa, a qual, por sua vez, dava-lhe alguma coisa em troca e saía. Tal conduta do réu foi avistada por policiais. O acusado foi abordado e durante a revista acharam com o acusado 2 papelotes de maconha e mais 2 invólucros contendo cocaína, além de R\$ 35,00. A seguir, na viela onde o acusado entrava seguidamente, foi encontrado um saco plástico contendo as demais porções de droga e R\$ 50,00.

Auto de prisão em flagrante (fl. 01). Boletim de ocorrência (fls. 07/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12 e 64/65). Laudo de constatação (fls. 14/19 e 66/71).

Foi concedido alvará de soltura ao acusado, após concessão de outras medidas cautelares, contudo, diante de notícia de descumprimento, foi decretada a prisão preventiva (fls. 91/92).

Notificado, o réu apresentou defesa preliminar às fls. 103/109.

Mandado de prisão cumprido às fls. 139.

A denúncia foi recebida em 24/02/2022, às fls.146/147.

Laudo pericial definitivo (fls. 213/215).

Em audiência foram ouvidas testemunhas e interrogado o acusado (fls. 298/303).

Na fase de debates, o Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela procedência do pedido acusatório. No que tange à dosimetria da pena, argumentou que na primeira fase deve a pena ser aumentada diante de circunstâncias do art. 42 da lei de drogas, havendo variedade de drogas. Ademais, afirmou que nada há na segunda etapa e que na terceira etapa, diante da diversidade das drogas, não caberia o reconhecimento de tráfico privilegiado, sendo o réu traficante habitual, havendo outra prisão dos fatos em data próxima aos fatos. Requereu a fixação de regime inicial semiaberto.

A defesa do réu requereu em alegações finais de fls. 216/225 a absolvição do acusado, sustentando que o acusado não cometeu o delito e por inexistir provas para a condenação. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para o delito de porte para uso próprio, ou ainda, tráfico privilegiado, aplicando redutor no máximo. Requereu que seja a pena fixada no mínimo legal, com regime aberto e detração de período em que esteve preso, substituindo a pena por restritiva de direitos. Pugnou que seja deferido ao réu recorrer em liberdade.

A defesa apresentou manifestação às fls. 304/310, requerendo a liberdade provisória do acusado, e o Ministério Público se manifestou às fls. retro.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal penal é procedente.

A materialidade do delito de tráfico está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, laudo de constatação da substância entorpecente, laudos periciais e prova oral produzida.

A sua autoria segue a mesma sorte.

Passo à análise da prova oral colhida no feito:

A testemunha Alexandre Armando Fernandes Moraes relatou que estavam em diligência em Arujá, sendo policial em Guarulhos. O acusado estava de frente a uma residência e ficaram observando. Ele saía do local e ia numa viela e entregava a pessoas. Disse que abordaram o acusado, que tinha duas porções de cocaína e de maconha. Na viela encontraram uma sacola com crack, cocaína e maconha. O acusado confirmou que estava traficando drogas. Visualizaram por instantes a movimentação do acusado, pois estavam em viatura descaracterizada. Sabiam que o local era ponto de venda de

drogas, pois já trabalharam em Arujá e resolveram diligenciar pelo local. Nos instantes que ficaram na viatura viram pessoas se aproximando do réu e ele indo para a viela. Foram ao local da abordagem pois já sabiam do local, e pelo o réu estar ali parado foi chamada a atenção, pela atitude do acusado. Afirmou que estava com dois parceiros, na viatura descaracterizada. O réu tinha acabado de descer da viela e chegou um rapaz para conversar com o réu. Pararam a viatura na frente e abordaram o acusado, que não resistiu. O rapaz ao lado não tinha nada e foi liberado, pois disse que estava passando, mas dele ter ido comprar drogas. Com o acusado acharam as duas porções de maconha e duas de cocaína, e por isso foram com ele para a viela e no muro havia um saco preto com as demais porções de drogas. Também acharam R\$ 85,00 com o acusado. Disse que não havia investigação e o réu foi abordado por estar parado em rua sem movimento e ao lado da viela, perto de ponto de drogas. Não filmaram o acusado vendendo drogas, pois não havia investigação anterior, sendo o acusado abordado pelo flagrante mesmo. Narrou que nas outras vezes que foi ao local não tinha visto o réu traficando, não o conhecendo. Disse que a esposa do acusado apareceu durante a abordagem, que foi na frente da casa do réu. Ela franqueou a entrada e nada foi encontrado na casa dele. Declarou que na sacola apenas havia entorpecente. O réu subia na viela, descia e entregava algo a pessoas, o que era bem perto. Disse que não sabe precisar a distância, mas seria algo em torno de 20 ou 30 metros. A sacola estava num buraco de tijolo do muro da viela. A forma de embalagem é idêntica àquela que estava no bolso do réu. Disse que cada local que trafica tem suas embalagens. Houve um rapaz que estava perto e que correu. No momento da abordagem não havia outras pessoas além desse rapaz que foi liberado. Tinha umas pessoas num bar de garagem que era perto. A viela interliga a Rua 48 com outra rua. Disse que o acusado ficou com seu parceiro enquanto subia a viela, na qual achou as drogas no muro. O réu ficou no pé da viela com seu parceiro. Subiu só a viela.

A testemunha Dom Francisco Fernandes Floriano declarou que viram o comportamento do acusado, efetuando com parceiros o flagrante. Estava com os parceiros em operação da seccional e o acusado tinha comportamento estranho, pois ficaram observando ele, em local que é ponto de venda de drogas. Na viela encontraram a droga. Disse que o acusado estava indo e voltando na viela e frente de residência, e ia para a viela quando chegava alguma pessoa e conversava com o acusado. Disse que o acusado foi abordado por tal comportamento. Estavam em três policiais e foi ele e o Ricardo quem ficou com o réu e o Alexandre achou as drogas na viela. Onde estavam dava para enxergar a viela e Alexandre achando a droga. Disse que a abordagem ocorreu em razão de passarem no local e perceberem o comportamento estranho do réu, resolvendo verificar se ele estava traficando. Declarou que na revista pessoal do acusado foi encontrada alguma quantidade de droga, cerca de 4 porções, entre maconha e cocaína. Entraram na residência do acusado, após a abordagem, pois a esposa do réu apareceu. A casa do réu era bem à frente da abordagem e a esposa franqueou a entrada na casa dele. Na casa do réu nada foi encontrado e entraram no local após a abordagem e encontro de drogas na viela. Afirmou que um indivíduo correu quando chegaram ao local para a abordagem do acusado.

A testemunha Eduardo dos Santos Silva declarou que conhece o réu há muitos anos, trabalhou com ele e sabe que mora perto de uma viela. Afirmou que nunca viu o réu traficando e sabe que ele foi preso, mas nunca o viu vendendo drogas. Narrou que desde criança conhece o réu e sabe que ele sempre teve problema de saúde, pois “não tem juízo muito certo”. O acusado está na escola especial, na Apae e sempre tomou medicamentos. Pela experiência que possui o réu tem discernimento com prejuízo. O réu sempre morou perto da viela, que é acesso comum de moradores do bairro. Trabalha para recapeamento na SPtrans e o acusado trabalhou com ele em tal serviço. O réu trabalhou um ano e meio com ele e sempre tomou medicamentos, e o efeito que causava era deixar o acusado tranquilo, controlado. Depois o réu virou usuário de maconha. Sabe que ele foi preso outra vez por isso.

O acusado Maurício Barbosa de Souza declarou em interrogatório judicial que tem 30

anos, é ajudante de carga e descarga, fazia bicos quando foi preso e ganhava R\$ 780,00 no mês. Estudou em escola especial de Arujá, no ensino médio. É separado e tem dois filhos, de 05 e 01 anos de idade. As crianças estão com sua mãe. Disse, em relação aos fatos, que após a abordagem estava em frente de casa e só acharam "duas maconhas" no seu bolso. Entraram na sua casa, quebraram o guarda-roupa, não acharam nada. Após os policiais foram na viela e voltaram com sacola na mão, falando que era dele. Disse que essa sacola não era dele. Tinha ido antes de ser abordado na padaria e quando chegou no portão foi abordado. Declarou que o local que reside é perto de ponto de tráfico. Disse que somente foi duas vezes na padaria, indo comprar pão e na segunda vez chocolate, pois tinha esquecido de comprar esse. Não costuma ir na padaria com entorpecente no bolso, mas tinha acabado de pegar a droga que tinha consigo na viela com uns rapazes. Eles estavam traficando na viela. Disse que quando foi abordado os rapazes jogaram fora a sacola. Perguntado porque não foi dito isso antes no interrogatório, não respondeu. Afirmou que trazia consigo apenas "duas maconhas de cinco reais", que estavam no seu bolso, e comprou quando saiu para comprar o chocolate para seu filho. Foi abordado no retorno da padaria e essa maconha era para seu uso, devido a problemas "de cabeça", que o levaram a fumar maconha. Disse que não acompanhou os policiais quando a sacola foi encontrada, pois ficou imobilizado no portão, na porta de sua casa. "Dom" foi quem ficou com ele, depois o Alexandre voltou com a droga e disse que era sua. Afirmou que a droga foi encontrada duas casas após da viela e onde estava não conseguiu avistar ele encontrando a droga. Alexandre voltou com a sacola e jogou no seu colo, dizendo que era sua. Após a polícia entrou na sua casa. A polícia entrou na sua casa após encontrar a droga. Nesse dia havia mais pessoas na viela. É uma rua de passagem. Faz tratamento no CDP e toma medicação.

Essa foi a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

O acusado negou o cometimento do delito, afirmando que tinha saído de sua casa na data dos fatos para ir à padaria, por duas vezes, e que acabou sendo abordado pela polícia. Negou que era o possuidor da sacola que continha drogas, mas confirmou que em seu bolso havia 2 porções de maconha, alegando ser usuário. Negou ter ido com os policiais à viela, onde foi encontrada a droga. Primeiramente afirmou que os policiais entraram na sua casa e depois foram à viela, e depois, ao final do interrogatório, aduziu que os policiais primeiro foram à viela e depois ingressaram em sua residência.

Em delegacia o acusado prestou depoimento semelhante, no sentido de que teria apenas maconha em seu poder, para uso próprio, negando a posse de sacola que continha drogas, que pertenceriam a outros indivíduos. Afirmou em delegacia que foi com os policiais na viela, na qual acharam as demais porções de entorpecentes. (fls. 05).

Assim, nota-se que a versão dos fatos apresentada pelo acusado em juízo traz divergências em relação à dinâmica do que ocorreu durante a abordagem policial, pois o réu primeiro aduz que a polícia ingressou na sua casa e após foi à viela, e poucos minutos depois, faz afirmação ao contrário. Ainda, o réu, diferentemente do que disse em delegacia, negou em audiência de instrução ter ido à viela com os policiais, quando ocorreu o encontro de drogas numa sacola.

Os policiais ouvidos como testemunhas relataram que ao chegarem ao local dos fatos o acusado estava apresentando comportamento estranho, e que ficaram numa viatura descaracterizada, observando que o acusado recebia pessoas, e saía para a viela, retornando em seguida. Afirmaram os policiais que o réu tinha em seu poder duas porções de cocaína e duas porções de maconha, sendo os demais entorpecentes encontrados na viela para onde o acusado se dirigia a todo momento. Confirmaram os policiais que no momento da abordagem do réu um outro indivíduo desconhecido teria se evadido, correndo, e outro, de bicicleta, teria sido liberado por não ter nada consigo, sendo indivíduo que chegou ao local para conversar com o acusado pouco

antes da abordagem.

Com o acusado foi encontrada a quantia de R\$ 35,00 e na sacola com as demais porções de entorpecentes havia mais R\$ 50,00.

Pois bem.

Vê-se que a versão do acusado de que não estava com as drogas apreendidas e que somente teria sido abordado após ter ido duas vezes à padaria não se mostra crível, não tendo trazido o acusado aos autos qualquer elemento de prova passível de gerar alguma dúvida no tocante a sua culpabilidade, e com isso, ensejar a aplicação do princípio in dubio pro reo.

A testemunha arrolada pela defesa não presenciou os fatos, somente tecendo considerações sobre trabalho anterior do acusado e sobre o uso de medicamentos pelo réu, o que foi por este confirmado.

No mais, tem-se que, como dito, a versão do réu em juízo diverge daquela apresentada em delegacia.

Ademais, durante o interrogatório judicial o réu somente mencionou o encontro de porções de droga em seu bolso após a pergunta pelo órgão acusador, não sendo razoável que tenha se esquecido de tal fato.

Conforme narraram os policiais, estes permaneceram durante certo tempo em campana, percebendo a ação do acusado, que atendia pessoas, saía para a viela, que era próxima, e retornava contato com a pessoa, o que é atitude que indica tráfico de drogas.

Também, o mero fato de outro indivíduo desconhecido correr no momento da chegada dos policiais não altera o entendimento ora exposto, uma vez que a conduta do acusado restou evidente, pois houve encontro de drogas em seu poder, que estava com embalagem idêntica àquela da maior porção de droga localizada na viela, tendo sido ainda localizado com o acusado certa quantia em dinheiro.

Com efeito, embora não se possa utilizar elementos do inquérito policial como prova, no caso em questão, é a própria versão do acusado em juízo que, contraposta aos relatos dos policiais e às demais provas colhidas, termina por conduzir à certeza de culpabilidade.

Este juízo vem sempre consignando que não seria demais exigir do órgão acusador, a quem se impõe o ônus probandi, a juntada de outras provas que não se limitem às declarações dos policiais que foram responsáveis pela prisão do agente, e que hoje já existem outros instrumentos e mecanismos aptos a robustecer os motivos ensejadores da prisão e da persecução penal, como gravações audiovisuais para registrar as abordagens, diligências e operações. Não obstante, as circunstâncias específicas do caso, mormente em relação às declarações contraditórias do acusado, revelam uma versão defensiva muito frágil e pouquíssimo convincente, a qual, por sua vez, acaba oferecendo elementos sobre a abordagem que se coadunam com a dinâmica relatada de forma uníssona pelos policiais, terminando por constituir um conjunto probatório suficiente à prolação de um decreto condenatório em desfavor do acusado.

No mais, o exame toxicológico confirmou a natureza entorpecente das drogas localizadas (fls. 213/215).

Recorda-se que o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla, de modo que se consuma com qualquer das outras condutas descritas no mencionado dispositivo legal, como, transportar, trazer consigo, guardar, ter em depósito,

entregar a consumo e fornecer drogas, ainda que gratuitamente. Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESES DE QUE A PROVA OBTIDA NOS AUTOS É ILÍCITA, E DE QUE O CRIME É IMPOSSÍVEL, POR NÃO TER CHEGADO AO DESTINO, QUE NÃO FORAM VENTILADAS NAS RAZÕES RECURSAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDUTA DE TRANSPORTAR OU TRAZER CONSIGO, COM O INTUITO DE FORNECER, AINDA QUE PARA GRATUITO CONSUMO ALHEIO, QUE SE SUBSUME AO TIPO PREVISTO NO CAPUT DO ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA E CONTEÚDO VARIADO. CONSUMAÇÃO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. [...] 2. "Transportar", "trazer consigo" ou "fornecer ainda que gratuitamente" substância entorpecente ilícita são São Paulo núcleos do tipo do delito de tráfico de drogas - crime de perigo abstrato, de ação múltipla e conteúdo variado, que se consuma com a prática de quaisquer das ações insertas no art. 33 da Lei Antidrogas. (HC 225555/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, j. em 09/12/2012).

Nota-se que a prova existente nos autos é suficiente para a condenação dos acusados pelo delito de tráfico de drogas.

Observo que a defesa não pugnou pela instauração de incidente de insanidade mental ou de dependência toxicológica e desistiu de sua tramitação (vide termo de audiência fls. 302/303), e o alegado uso de medicamentos não é circunstância relevante ao julgamento da demanda, não havendo indícios de que o réu, ainda que usuário de drogas, não detivesse o necessário discernimento para entender o caráter ilícito do fato, não se comprovando qualquer causa excludente de culpabilidade.

Neste sentido:

Apelação Criminal. Tráfico de entorpecentes. Réu detido em flagrante na posse de 44,60g de crack. Recurso defensivo, alegando, preliminarmente, a configuração de nulidade processual por indeferimento do exame toxicológico. Nulidade não configurada. Inexistem nos autos elementos a justificar a necessidade de realização do exame. Insurgência revestida na intenção de obter declaração de imputabilidade. Réu não se mostrou incapaz, parcial ou totalmente, de entender o caráter ilícito da conduta. No mérito, argui a tese de inexigibilidade de conduta diversa. Impossibilidade. No máximo, o presente caso retrata a situação de traficante usuário, sendo o porte de droga para consumo próprio absorvido pelo delito de tráfico. Condenação. Penas dosadas nos patamares mínimos. Causa de diminuição aplicada no máximo. Contudo, a substituição, apesar de possível, não é indicada. Negado provimento. (TJSP; Apelação Criminal 0004285-62.2011.8.26.0483; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Venceslau - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 14/08/2012; Data de Registro: 24/08/2012)

Conforme a folha de antecedentes de fls. 208/212, o acusado é primário, devendo ser reconhecida a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, pois o réu ostenta bons antecedentes e inexistem nos autos comprovação suficiente de que se dediquem a atividade criminosa. Demais disso, a diversidade de drogas, embora seja considerável, não obsta o reconhecimento da minorante.

Nesse sentido, o aresto abaixo colacionado.

APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Associação para o tráfico de drogas. Recurso ministerial. Pleito de condenação dos apelados como incurso no artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/06. Provas suficientes de autoria e materialidade apenas em relação ao tráfico. Mantida a absolvição quanto ao delito previsto no artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/06, ante a ausência de provas no que tange à estabilidade e permanência do suposto grupo criminoso. Dosimetria das penas. Confirmado o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, no grau máximo. Primariedade, quantidade de droga que não se mostra

excessiva e inexistência de elementos que indiquem a dedicação à atividade criminosa ou integração a organização voltada à prática de delitos. Regime inicial aberto e substituição das penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos mantidos nos termos da r. sentença. Evidente erro material na r. sentença em relação às penas de multa. Viável a sua correção. Negado provimento ao recurso, com correção, de ofício, do erro material constante do dispositivo da r. sentença. (TJSP; Apelação 0046355-59.2016.8.26.0050; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 32ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/07/2017; Data de Registro: 12/07/2017) (grifos nossos)

Anoto ser incabível a desclassificação para o delito de porte para uso próprio, considerando a quantidade de drogas apreendidas em poder do réu e a comprovação de que ele realizava a venda de entorpecentes a terceiro, o que foi visualizado por policiais em campanha, tendo o réu, como já mencionado, apresentado versão contraditória dos fatos.

Inexiste qualquer causa excludente de ilicitude ou que isente o réu de pena.

No mais, a ação foi culpável, reprovável, pois o réu era (e ainda é) ao tempo da conduta imputável, tendo consciência da ilicitude de suas ações. Não há, portanto, qualquer causa excludente da culpabilidade.

Isto posto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de condenar MAURÍCIO BARBOSA DE SOUZA, qualificado no autos, como incurso no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Apurada a responsabilidade penal, passo a dosar a pena de condenação.

Assim, primeiramente, no tocante às circunstâncias judiciais, verifico que o réu agiu com a culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar nesse sentido. Não há nos autos elementos concretos que permitam uma valoração da sua personalidade. O réu não possui maus antecedentes (fls. 208/212). O motivo do delito se constituiu pela obtenção do lucro fácil, que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito. Nada há, em concreto, que desabone a sua conduta social. As consequências do crime não se mostraram de maior monta. As circunstâncias também não se revelam desfavoráveis ao acusado, lembrando que a quantidade e natureza da droga não apresentam expressão ou magnitude aptas a ensejar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Diante disso, imponho ao réu a pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, no menor valor legal.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Ausentes causas de aumento.

Presente, todavia, como já asseverado alhures, a causa de diminuição de pena do § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06, uma vez que o réu é primário, não possuindo antecedentes, não havendo ainda provas suficientes de que se dedique a atividades criminosas ou de que integre organização criminosa, não tendo sido produzida pela acusação prova bastante de vínculo aprofundado e estável com o comércio espúrio, para cujo reconhecimento seria necessária a existência de prova cabal neste sentido.

Neste ponto, vale mencionar a manifestação de César Dário Mariano:

Presentes os requisitos previstos na norma a diminuição da pena é obrigatória, não

ficando ao alvedrio do Juiz operar a redução ou não. Embora a norma empregue a expressão “as penas poderão ser reduzidas”, não se trata de atividade discricionária do Juízo, mas de direito subjetivo do acusado. Aliás, a primariedade e bons antecedentes deverão ser demonstrados pelo acusado, ao passo que caberá ao Ministério Público o ônus de provar que o réu se dedica à atividade criminosa ou que pertence à organização criminosa. Não cabe ao réu a prova de fatos negativos, mas a quem alega, no caso, o Ministério Público.

(...) Dedicar-se a atividades criminosas pressupõe reiteração de condutas tipificadas como crime, ou seja, habitualidade no cometimento de delitos. Tal circunstância poderá ser demonstrada por meio de folhas de antecedentes criminais, certidões cartorárias, cópias de outros processos, testemunhas, ou seja, qualquer meio hábil a provar a vida criminosa do acusado. Como a norma não diz qual espécie de atividade criminosa poderá ser qualquer uma, desde que, obviamente, não se trate de delitos culposos, que pressupõem ausência de vontade.

A norma visa a impedir a redução da pena para aquele que de forma habitual e deliberada pratica qualquer espécie de crime. Com efeito, aquele que faz da vida criminosa seu modo de vida não é merecedor do redutor. (Silva, César Dario Mariano da Lei de drogas comentada / César Dario Mariano da Silva. -- 2. ed. -- São Paulo : APMP - Associação Paulista do Ministério Público, 2016).

Em sentido semelhante:

“A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena” (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).

Ainda, é preciso salientar que com o acusado não foi encontrado qualquer tipo de armamento, ou quantia mais expressiva em dinheiro e o crime, ao que consta, não envolveu qualquer tipo de ameaça, violência ou intimidação.

Outrossim, a diversidade de natureza de drogas, a par de não ser elemento suficiente a afastar a minorante, também não o é para modular a fração do benefício.

Nesse sentido, o recente julgado do STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO PERMITEM AFERIR A DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA E, PORTANTO, NÃO SE PRESTAM PARA JUSTIFICAR O AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAR A FRAÇÃO DESSE BENEFÍCIO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (RECURSO ESPECIAL Nº 1925096 – SP - RELATORA: MINISTRA LAURITA VAZ - Brasília, 02 de agosto de 2021). (grifos nossos).

Do mesmo modo, o fato de o réu possuir outro inquérito e processo criminal em andamento, sem condenação transitada em julgado, não pode obstar a aplicação do redutor. Ainda, pontuo que o outro delito que consta em sua folha de antecedentes é posterior ao ora analisado, pois datado de 12/10/2021 (fl. 211).

A propósito:

Aliás, por ocasião do julgamento do HC n. 602.611/DF (Rel. Ministro Rogerio Schietti), ocorrido em 17/11/2020, esta colenda Sexta Turma, à unanimidade, seguiu a compreensão do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria (com a minha ressalva pessoal) e, assim, reconheceu a incidência do redutor em favor de réu que havia tido o benefício negado com base, tão somente, em processos em andamento e condenação ainda não transitada em julgado. Diante de tais considerações, firme na

importância de se observarem os precedentes e de se adotar interpretação uniforme das leis - até para garantir uma ordem jurídica mais coerente, mais estável e com maior previsibilidade quanto à interpretação adotada pelo Poder Judiciário -, curvo-me ao posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, para reconhecer a inidoneidade do segundo fundamento apontado no caso para justificar a impossibilidade de incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em favor do paciente, qual seja, a existência de processos ainda em andamento. Portanto, à ausência de fundamento suficiente o bastante para justificar o afastamento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, deve a ordem ser concedida, inclusive liminarmente, a fim de aplicar, em favor do réu, o referido benefício. ((STJ - HC: 749417 ES 2022/0183000-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 20/06/2022)).

Nesse contexto, à míngua de outras causas modificadoras, fica o réu MAURÍCIO BARBOSA DE SOUZA, definitivamente condenado por tráfico de drogas privilegiado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, cumulada com 166 dias-multa, no mínimo legal, pena esta que torno definitiva.

Do regime inicial de cumprimento de pena e alternativas penais:

O parágrafo 4ª do art. 33 da lei 11.343/06 de forma louvável, admitiu em casos como o ora analisado, a possibilidade de redução da pena imposta ao acusado primário e de bons antecedentes em até 2/3. A previsão legal de uma causa de diminuição de pena nestas circunstâncias tratou de prestigiar da forma adequada o princípio constitucional da individualização da pena, reconhecendo uma situação fática que salta aos olhos do operador do direito: o de que traficantes eventuais, de bons antecedentes e que nunca se envolveram em organizações criminosas não podem ser equiparados aos grandes comerciantes de drogas, verdadeiros empresários do tráfico, responsáveis por manter toda uma rede articulada de produção e distribuição de drogas, auferindo grandes lucros da atividade e fomentando o cometimento de outros tantos delitos graves. Como se vê, são duas espécies distintas de criminosos a justificar tratamentos diversos pela lei penal.

Estranhamente, o próprio dispositivo legal supra aludido, de forma incongruente, negava expressamente a possibilidade de substituição da pena privativa em pena restritiva de direito, afastando-se, desta feita, dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, e, como tal, do próprio princípio da individualização da pena que, de início, parecia pretender alcançar.

Não há dúvida, como mencionado alhures, que a reprovabilidade da conduta do traficante ocasional é menor do que a dos grandes traficantes de droga responsáveis por coordenar e alimentar a grande cadeia do tráfico ilícito de entorpecentes. Eis a razão pela qual a nova lei de drogas, de forma feliz, reconheceu a culpabilidade atenuada daqueles pequenos criminosos, permitindo uma razoável diminuição da pena que eventualmente lhe venha a ser imposta.

Todavia, a concretização da máxima da individualização da pena não se esgota na dosagem da quantidade de pena aplicada ao réu, mas também se funda na determinação de sua qualidade ou natureza. Se a culpabilidade do réu é de menor grau, sustentando a lei uma diminuição da pena imposta, não subsiste razão jurídica para obstar ao réu a concessão de benefícios penais condizentes com a sua menor culpabilidade.

A substituição da pena privativa por restritiva de direito é mecanismo salutar e consentâneo com os primados do Estado Democrático de Direito em que vivemos, sendo, em caso como ora apresentado, bastante a demonstrar a reprovação do Estado com relação à conduta perpetrada pela agente, evitando-se assim os males que o sistema carcerário acarreta, mormente no tocante a presos que cometeram pequenos delitos,

como o ora acusado.

A vedação outrora inserta no art. 33, §4º da lei 11.343/06 que impedia a substituição da pena privativa imposta revelava-se incoerente e arbitrária, destoando dos preceitos constitucionais aos quais deve estar atrelada, motivo pelo qual deveria ter sua aplicação afastada. Aliás, tal providência é hoje desnecessária, uma vez que o Senado Federal, desde 16.02.2012, seguindo a linha da jurisprudência dos tribunais, resolveu por bem baixar a resolução nº 05/2012, suspendendo a expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” constante do § 4º do art. 33 da lei 11.343/06, de modo que desde tal data, não subsiste mais qualquer empecilho legal à substituição da pena nos casos de tráfico privilegiado.

Também afastada deve ser a regra inserta no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, por determinar o cumprimento inicial da pena imposta por tráfico de entorpecentes, sempre no regime fechado, pelas mesmas razões declinadas relativas ao dispositivo que vedava a substituição da pena.

Aliás, o próprio STF, já vem entendendo - além da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito - pela inaplicabilidade da lei de crime hediondos a hipóteses de tráfico privilegiado, como o presente caso:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA .1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida. (HC 118533, Relator(a): Min. CÂRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 16-09-2016 PUBLIC 19-09-2016)

PENA - REGIME FECHADO - INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1º, § 1º, DA LEI Nº 8.072/1990. A imposição do regime inicial fechado, prevista na Lei de Crimes Hediondos, é inconstitucional, considerado o princípio da individualização da pena. Precedente: habeas corpus nº 111.840, relator o ministro Dias Toffoli, julgado pelo Pleno em 27 de junho de 2012, acórdão publicado no Diário da Justiça de 17 de dezembro de 2013. PENA - TRÁFICO DE DROGAS - SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DA LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS - INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 44 DA LEI Nº 11.343/2006. A vedação à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, prevista na Lei de Tóxicos, é inconstitucional, ante o princípio da individualização da pena. Precedente: habeas corpus nº 97.256, relator o ministro Carlos Ayres Britto, julgado em 1º de setembro de 2010 pelo Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 16 de dezembro imediato. PENA - EXECUÇÃO - REGIME DE CUMPRIMENTO. Não se tratando de réu reincidente, ficando a pena no patamar de 2 anos e sendo as circunstâncias judiciais positivas, cumpre observar o regime aberto e apreciar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos - artigos 33 e 44 do Código Penal. (HC 129714, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 25-04-2017 PUBLIC 26-04-2017) (grifos nossos)

Esse mesmo entendimento vem sendo seguido pelo STJ, senão vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA

PENA. LEGALIDADE. RECENTE ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS E OBJETIVAS QUE RECOMENDAM A REDUÇÃO MÁXIMA. REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO. PACIENTE PRIMÁRIA, CONDENADA À PENA QUE NÃO EXCEDE 4 ANOS, COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, entendeu que a possibilidade de início da execução da pena condenatória após a confirmação da sentença em segundo grau não ofende o princípio constitucional da presunção da inocência (HC n.126292, julgado no dia 17 de fevereiro de 2016). 3. No caso, a jurisdição das instâncias ordinárias encontra-se encerrada, porquanto na fase de admissibilidade do recurso especial interposto pelo paciente, sendo possível dar início à execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, sem que isso importe em violação do princípio constitucional da presunção de inocência. 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 5. No caso, verifico que a quantidade de entorpecentes não é expressiva para aplicar a fração em patamar diverso do máximo, com relevo para o fato de que a paciente era menor de 21 anos na data do fato, é primária, está grávida e já está inserida no mercado de trabalho. Assim, o redutor comporta aplicação em seu patamar máximo. 6. Em relação ao regime, cumpre asseverar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/1990, com a redação dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, determinando, também nesses casos, a observância do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, c/c o art. 59, do Código Penal. 7. No caso, o regime fechado, mais severo do que a pena comporta, foi fixado com base na hediondez do delito e na gravidade abstrata da conduta, fundamentos que não são considerados idôneos para fixar o regime mais gravoso. 8. Dessa forma, tratando-se de ré primária, condenada à pena privativa de liberdade não superior a 4 anos de reclusão, com a análise favorável das circunstâncias judiciais, a paciente faz jus ao regime aberto, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, assim como resulta cabível a conversão da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos. 9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para restabelecer a sentença. (HC 391.679/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017)

Com efeito, seguindo a linha do que vem sendo sustentado pelos tribunais superiores, é, de fato, inevitável o reconhecimento da invalidade da norma proibitiva do início de cumprimento da pena em regime diverso do fechado pela violação ao devido processo legislativo, por não observar os comandos constitucionais de individualização da pena, porque, embora tenha cominado para o mesmo crime penas diversas em razão das condições pessoais dos acusados, com reconhecimento do excesso de penas ao primário, exige-lhe igual recolhimento ao cárcere, em regime fechado, a afrontar também o princípio da proporcionalidade.

Não se pretende assumir poderes legislativos, mas a aproximação do Direito Penal ao Direito Constitucional implica interpretar as normas penais ao influxo da Constituição da República para verificação da validade daquelas normas que, inevitavelmente, devem conter os direitos fundamentais, além de serem proporcionais e razoáveis às relações humanas, princípios impeditivos de excessos, da pena desnecessária.

Com essa convicção, resultante da interpretação da norma infraconstitucional ao influxo da Constituição da República, consideradas as circunstâncias judiciais favoráveis, o regime inicial será o ABERTO, que deve ser estabelecido com observância às circunstâncias judiciais, conforme determina o art. 33, § 3º, do Código Penal. Fixada a pena-base no mínimo legal, o regime inicial deve ser adequado à quantidade da pena, que no presente caso permite o estabelecimento do regime aberto, porque o acusado não é delinqüente contumaz, como pode ser inferido das provas acostadas e folha de antecedentes.

Atendidas as condições previstas art. 44, incisos I a III, e art. 77, "caput", inc. III, do Código Penal, com os fundamentos antes apontados, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo prazo da pena original, a ser especificada em sede de execução penal. Sendo a pena privativa de liberdade superior a um ano, aplico também a pena restritiva de direito consistente na prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo a entidades públicas ou privadas, a ser especificada pelo juízo de Execução, sem prejuízo do pagamento dos 166 dias-multa já fixados.

Assim, fica o réu MAURÍCIO BARBOSA DE SOUZA definitivamente condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, para início no REGIME ABERTO, que SUBSTITUO por prestação de serviço à comunidade ou entidade pública pelo mesmo prazo, e ao pagamento de 01 (um) salário mínimo como prestação pecuniária, além de 166 dias-multa cominado no tipo penal, no valor mínimo legal.

O réu está preso desde 16/02/2022 (fl. 139). Deixo de aplicar o disposto no §2º, do art. 387, do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei nº 12736/12, uma vez que, mesmo computado o tempo em que o réu esteve preso provisoriamente, não haveria alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Do direito do réu apelar em liberdade:

O réu respondeu preso ao processo e concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, tendo em vista a pena aplicada, a sua substituição e o regime fixado, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo razões para prisão preventiva.

Expeça-se alvará de soltura clausulado ao réu Maurício Barbosa de Souza.
DISPOSIÇÕES GERAIS:

Recebido eventual recurso promovido por qualquer das partes, extraia-se carta de guia provisória, em favor do réu à Vara das Execuções Criminais competente.

Após o trânsito em julgado da presente decisão condenatória, determino:

- a) Lançamento do nome dos condenados no Rol dos Culpados.
- b) Apuração dos valores das penas de multa aplicada aos sentenciados.
- c) Comunicação à Justiça Eleitoral que os sentenciados encontram-se com seus direitos políticos suspensos, face ao disposto no artigo 15, III, da Constituição Federal.

d) Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno os réus a pagarem a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhes a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

e) Se for o caso, expeça-se certidão de honorários advocatícios ao(s) Defensor(es) nomeado(s) no grau previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

f) Nos termos do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal, com a redação da Lei 11.690/09, comuniquem-se as vítimas da sentença.

g) Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos, consoante o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação da Lei 11.719/08, pois não foi possível avaliar com precisão os prejuízos sofridos pelas vítimas, que poderão se socorrer das vias idôneas.

h) Determino a perda dos valores e bens apreendidos com o acusado, na forma do art. 43 e 45, §3º, ambos do CP.

g) Com fundamento no art. 58, § 1º, da Lei nº 11.343/06, inexistente controvérsia acerca da qualidade e quantidade da droga, autorizo a incineração, preservada pequena porção para eventual contraprova, com comunicação à Autoridade Policial.

Cautelas e comunicações de estilo.

Expeça-se alvará de soltura clausulado ao réu.

P.I.C.

Aruja, 06 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA